

1033539-62.2022.8.26.0100
Classe: Embargos à Execução
Assunto: Pagamento
Magistrado: Miguel Ferrari Junior
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Cível
Vara: 43ª Vara Cível
Data de Disponibilização: 29/06/2022

... favor do interesse geral do comércio, do tráfico mercantil? Em nossa ordem jurídica, a resposta é negativa. Os acordos pré-contratuais podem ser relevantes do ponto de vista moral, e até mesmo auxiliar o bom andamento das negociações. Porém, sua execução específica, de forma a obrigar à celebração a parte que desiste do negócio, é bastante difícil." (PAULA A. FORGIONI, Contratos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de SÃO PAULO
Foro Central Cível
43ª Vara Cível

1033539-62.2022.8.26.0100 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1033539-62.2022.8.26.0100
Classe - Assunto
Embargos à Execução - Pagamento
Embargante:
Tudophone Comércio de Telefonia e Assistência Técnica Ltda e outro
Embargado:
BANCO SAFRA S/A
Vistos.

Trata-se de embargos à execução opostos por TUDOIPHONE COMÉRCIO DE TELEFONIA LTDA. ME e CLEITON RODRIGO CASTELHANO em face de BANCO SAFRA S/A. Os embargantes invocam a incidência do Código de defesa do Consumidor e pedem a aplicação da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva em razão dos fatos descritos.

O embargado não apresentou resposta.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Em primeiro lugar, mister se faz destacar a não incidência dos efeitos da revelia nos embargos do devedor. Isso porque: "Os títulos têm dupla função: servem como condição para que se utilize do procedimento executivo (sem passar pela etapa de conhecimento do processo) e tem caráter probante da obrigação, fazendo supor, até prova concreta em sentido contrário, a razão do exequente." (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, O Novo Processo Civil, Thomson Reuters Revista dos Tribunais, página 474).

Demais disso: "A caracterização da revelia nos embargos à execução depende da matéria sobre que incide. Se o embargado deixar de impugnar as questões referentes ao direito objeto do título, não incide a presunção de veracidade, já que essa presunção se antagonizaria com a presunção (de existência do direito) que é inerente ao título executivo. Nesse caso, as partes deverão demonstrar suas alegações, da forma comum. Por outro lado, se é alegado defeito no próprio processo de execução (por exemplo, vício de penhora, avaliação errônea dos bens ou cumulação indevida de execuções), o silêncio do exequente-embargado implica a aceitação da veracidade das alegações do embargante." (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, O Novo Processo Civil, Thomson Reuters Revista dos Tribunais, página 495).

Dito isso, passemos ao exame das matérias veiculadas.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre os contratos bancários é

questão pacificada tanto no Superior Tribunal de Justiça (súmula 297), quanto no Supremo Tribunal Federal (ADI 2591/DF, rel. orig. Min. Carlos Velloso, rel. p/ o acórdão Min. Eros Grau, 7.6.2006).

Este diploma normativo, todavia, não tem incidência sobre o contrato ora sob exame, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes ora litigantes não é de consumo.

De fato, o empréstimo tomado pelos embargantes destina-se ao implemento de sua atividade empresarial e não à satisfação de uma necessidade própria. A embargante Tudoiphone Comércio de Telefonia e Assistência Técnica não pode ser reputada destinatária final do dinheiro emprestado pelo embargado.

No caso, o dinheiro nada mais é do que um insumo adquirido pela embargante para propiciar o funcionamento de sua atividade empresarial. Com isso, estamos diante de uma relação jurídica de caráter civil, a qual deve ser regida pelo Código Civil.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTA CORRENTE. PESSOA JURÍDICA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALMEJADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DISCUTIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO INTERMEDIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 8.078/1990. I. Cuidando-se de contrato bancário celebrado com pessoa jurídica para fins de aplicação em sua atividade produtiva, não incide na espécie o CDC, com o intuito da inversão do ônus probatório, porquanto não discutida a hipossuficiência da recorrente nos autos. Precedentes. II. Nessa hipótese, não se configura relação de consumo, mas atividade de consumo intermediária, que não goza dos privilégios da legislação consumerista. III. A inversão do ônus da prova, em todo caso, que não poderia ser determinada automaticamente, devendo atender às exigências do art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/1990. IV. Recurso especial não conhecido. (RESP 716386/SP - Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR - DJe 15/09/2008)

No mesmo sentido é a doutrina do professor Fábio Ulhoa Coelho: "Não se discute que os atos de intermediação física praticados pelo empresário submetem-se à disciplina do direito cível. O âmbito de incidência do Código de Defesa do Consumidor é delineado pelo conceito de relação de consumo, e o empresário que adquire bens ou serviços para reinseri-los, ainda que transformados, na cadeia de circulação econômica não pode determinar-se como consumidor, pela legislação brasileira, visto que não é, nesse caso, destinatário final." (Curso de Direito Comercial, Direito de Empresa, Volume 3, 7ª. Edição, Editora Saraiva, página 183).

Dessa arte, o dinheiro tomado por empréstimo pelo empresário e empregado em sua atividade empresarial deve ser classificado como insumo, de modo a excluir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

De outro lado, os fatos invocados pelos embargantes são estritamente pessoais e não se referem à base objetiva do negócio jurídico entabulado entre as partes. Dito de outra forma, não são fatos que impactaram a estrutura do contrato, mas apenas o patrimônio dos devedores, o que não autoriza a incidência da teoria da imprevisão, conforme veremos adiante.

Antes de tudo, mister se faz analisar a própria admissão da revisão da base objetiva do negócio jurídico para adaptá-lo à realidade econômica com base na simples vontade do devedor afetado pela prestação desproporcional.

Em se tratando de relações jurídicas paritárias e submetidas ao regime civil ou empresarial, o Código Civil estipula que:

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato.

Da leitura das disposições normativas acima transcritas, deduz-se que o legislador pátrio fez uma opção muito clara e direta acerca da excessiva onerosidade. Com efeito, o próprio título da Seção IV do Capítulo II do Título V do Livro I da Especial dispõe acerca da resolução por onerosidade excessiva. Portanto, de acordo com o ordenamento jurídico em vigor, em caso de desequilíbrio

superveniente das prestações, o devedor afetado poderá pedir a resolução do contrato e não a sua revisão. Somente se o credor, réu da ação em que se pede a resolução, se dispuser a modificar equitativamente as condições do contrato, é que a resolução poderá ser evitada (artigo 479).

Por conseguinte, não se tem muita dificuldade para compreender que a posição majoritária que admite o pedido de revisão do contrato com base na excessiva onerosidade pelo devedor é contra legem, ou seja, à margem da lei.

Acerca do tema, assim se posiciona FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO MARINO:

Legitimidade para a oferta de modificação equitativa: "A leitura dos arts. 478 e 479 do Código Civil parece não dar margem à dúvida quanto ao titular do direito à revisão do contrato afetado pela excessiva onerosidade superveniente: o poder de realizar a oferta de modificação equitativa foi atribuída somente ao credor (art. 479), cabendo ao devedor excessivamente onerado apenas demandar a resolução da relação contratual (art. 478)." (Francisco Paulo De Crescenzo Marino, Revisão Contratual, Onerosidade Excessiva e Modificação Contratual Equitativa, Almedina, páginas 21). (...) "Frente a distintos modelos na experiência de outros países e diante de copiosa doutrina, o legislador de 2002 optou, conscientemente, por determinado regime geral da excessiva onerosidade superveniente, nitidamente inspirado no direito italiano. No sistema dos arts. 478 e 479 do Código Civil, cabe ao devedor da prestação tornada excessivamente onerosa pleitear unicamente a resolução da relação contratual, podendo o credor requerido evitá-la, oferecendo-se a modificar equitativamente as bases do contrato. O poder de modificar as bases do contrato não é conferido ao devedor, muito menos, ex officio, ao juiz. Diversa era a regra constante do Anteprojeto de Código de Obrigações (Parte Geral), de 1941, elaborado por comissão composta por Orosimbo Nonato, Philadelpho Azevedo e Hahnemann Guimarães, cujo art. 332 permitia ao juiz, a pedido do interessado, "modificar o cumprimento da obrigação, prorrogando-lhe o termo ou reduzindo-lhe a importância." O Anteprojeto de Código de Obrigações de 1963, de autoria de Caio Mário da Silva Pereira, a seu turno, continha regras notavelmente similares aos arts. 478 e 479 do Código Civil de 2002. A dinâmica dos remédios legais justifica-se por conta de uma desigualdade de posições entre as partes. Nesse quadro, soa compreensível, primeiramente, que o poder resolutório seja outorgado ao devedor, e apenas a ele, pois será dele o interesse em liberar-se do dever de prestar, ante o agravamento superveniente, considerável e imprevisível do custo da prestação. Mostra-se justificável, ademais, a atribuição do poder modificativo somente ao credor, dado o efeito econômico resultante da conservação do vínculo, correlatamente positivo para o devedor e negativo para o credor. Caso, como deseja a doutrina nacional majoritária, o poder modificativo fosse conferido ao devedor, o seu exercício tendencialmente levaria a impor ao credor ônus econômico superior àquele livremente assumido, mediante simples declaração do devedor ou mediante a atuação do juiz - em qualquer caso, sem o concurso do credor. Do exame dos argumentos sustentados pela doutrina extensiva do poder modificativo ao devedor, confirmam-se a lógica do sistema normativo e a legitimidade exclusiva do credor para a modificação equitativa do contrato. Resulta, ainda, ser a compreensão do sentido e do alcance do remédio revisional previsto no art. 479 uma condição prévia a qualquer crítica séria à sua alegada insuficiência. Nesse sentido, o estudo feito a seguir parece não somente contribuir para o entendimento do aludido dispositivo, mas também representar passo necessário a eventual proposta de remédio revisional paralelo, com incidência mais restrita." (Francisco Paulo De Crescenzo Marino, Revisão Contratual, Onerosidade Excessiva e Modificação Contratual Equitativa, Almedina, páginas 71-73).

(...)

"Retornando à discussão dos arts. 478 e 479 do Código Civil, no primeiro dispositivo a lei atribui ao devedor confrontado com o agravamento do custo de sua prestação, excessivo em relação à álea normal do contrato, o poder de resolver a relação contratual, liberando-se da obrigação assumida. A resolução contratual (com seu efeito liberatório) é, portanto, remédio legal de tutela do devedor contra a excessiva onerosidade da prestação a seu cargo. Frente a esse poder extintivo, unicamente atribuído ao devedor, a lei outorga ao credor, e somente a ele, um

contrapoder, de natureza modificativa, permitindo-lhe evitar a extinção do vínculo, desde que o reconduza à equidade. A disparidade de remédios atribuídos aos contratantes – poder extintivo do devedor e poder modificativo do credor – não chega a surpreender, diante das diversas hipóteses em que tais poderes são atribuídos a partes distintas ou até mesmo cumulados na titularidade do mesmo contratante (o que poderia soar ainda menos isonômico), como visto acima. Mas a opção legislativa parece justificável. A modificação equitativa da relação contratual terá sentidos e efeitos distintos para as partes. Para o devedor da prestação tornada excessivamente onerosa, o reequilíbrio significará a atribuição de uma vantagem econômica – seja por meio da redução de sua prestação, do incremento da contraprestação, da extensão de prazo para o adimplemento, da alteração benéfica do local ou da forma da prestação, dentre outras possíveis adaptações –, necessária para reconduzir a prestação ao alveio da álea normal. Para o credor, em contrapartida, o reequilíbrio implicará, ao menos tendencialmente, a assunção de um ônus econômico adicional em relação ao programa contratual originário. A dinâmica da lei explica-se, pois, a partir da desigualdade da posição das partes frente à manutenção do contrato cuja prestação foi afetada pela excessiva onerosidade superveniente. Em suma, a alusão à necessidade de tratar igualmente credor e devedor não se presta a fundar a extensão, ao devedor ou ao juiz, do poder revisional conferido ao credor ex art. 479. Pelo contrário, se se quiser raciocinar em termos de isonomia, ela estará atendida pela atribuição desigual de poderes jurídicos com posições jurídicas desiguais.” (Francisco Paulo De Crescenzo Marino, Revisão Contratual, Onerosidade Excessiva e Modificação Contratual Equitativa, Almedina, páginas 48-49).

Esta é a razão pela qual DARCY BESSONE defendia a solução legal, antes mesmo do Código de 2002: “Em certos casos, porém, o melhor remédio seria a revisão para a adaptação às novas condições, mas, a nosso ver, em caráter facultativo para o credor, a quem ficaria salvo preferir a resolução, porque, de outro modo, poderia ser conduzido a estipulações que não lhe conviessem. O devedor, no entanto, teria os seus efeitos minorados e seria colocado em posição melhor que a estabelecida pelo contrato, razão por que não poderia furtar-se aos termos da nova situação” (Bessone, Darcy. Do contrato: teoria geral. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 224).

“Como se vê, o sistema da onerosidade excessiva foi concebido como forma de resolução do contrato, não se prevendo a sua revisão, a não ser nas duas exceções contempladas nos dispositivos reproduzidos, vale dizer, (i) no caso de contrato sinalagmático de execução continuada, periódica ou diferida, mediante expressa anuência do credor (art. 479 do CC/2002), e (ii) no caso de contrato unilateral, que gera obrigações somente para uma das partes, quando o credor estará sujeito às modificações (redução ou alteração) que lhe forem judicialmente impostas, como forma de evitar o agravamento da prestação (art. 480 do CC/2002).” (LUIZ GASTÃO PAES DE BARROS LEÃES, A Onerosidade Excessiva no Código Civil, Doutrinas Essenciais, Direito Empresarial, volume IV, RT, páginas 167)

Acerca da Tutela constitutiva e tipicidade: “Porque a tutela constitutiva se traduz na modificação de situações jurídicas, indaga-se se ela só caberia nas hipóteses taxativamente previstas em lei. Preocupação dessa ordem se encontra na doutrina alemã e italiana; nessa última, especialmente por conta dos termos do art. 2.098 do Código Civil que, ao tratar da “tutela jurisdicional dos direitos”, condicionou o poder do juiz – de constituir, modificar ou extinguir relações jurídicas – às hipóteses “previstas em lei”. O receio está na possível similitude da tutela constitutiva com o juízo de equidade, em que o juiz faz a regra – ou a “justiça” – do caso concreto. Ademais, num ordenamento regido pelo princípio da autonomia da vontade, a razão da excepcionalidade residiria no fato de que a criação de efeitos jurídicos, por regra, dependeria da autonomia das partes e, somente em casos excepcionais, poderia advir da sentença. Eventual tipicidade da tutela constitutiva poderia contrastar com a atipicidade da ação e da tutela jurisdicional, no contexto do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. E, embora o sistema processual brasileiro desconheça regra semelhante à do ordenamento italiano, a questão é igualmente pertinente e relevante, vez que nela se contêm os limites da

atuação estatal (quanto à produção de efeitos jurídicos) e também porque a regra do sistema processual é de que os juízos de equidade são de exceção, diante da regra dos juízos de direito (CPC, art. 140, parágrafo único). Não obstante a preocupação seja fundada, é correto reconhecer a atipicidade dessa forma de tutela e, mais exatamente, remeter sua eventual tipicidade para o plano substancial do ordenamento. Aliás, em termos mais rigorosos não se poderia sequer falar em tipicidade da tutela, entendida como provimento favorável que impõe um determinado resultado, mas apenas da tipicidade dos fundamentos (causa de pedir) que autorizariam a respectiva invocação, em concreto. Assim, a ligação entre tutela constitutiva e direito material é a solução e o antídoto contra eventual risco de arbítrio na produção de efeitos jurídicos pelo juiz. Todas as formas de tutela que resultam da atividade jurisdicional no processo de conhecimento devem ser tratadas em um mesmo plano homogêneo, de tal sorte que um meio não deve ser considerado excepcional no confronto de outro. Dessa maneira, todo e qualquer efeito autorizado ou admitido no plano do direito material pode, em tese, ser produzido por provimento jurisdicional. Não é preciso que o ordenamento estatua a possibilidade da edição de uma sentença constitutiva porque isso já resulta da garantia geral da ação; mas sim que preveja a produção, modificação ou extinção de determinados efeitos no plano do direito material. Se, nesse plano, vigora ou não a regra de tipicidade é questão que o processualista enfrenta essencialmente de modo reflexo. A questão é particularmente delicada em se tratando de provimentos constitutivos positivos, uma vez que quando se trata de desconstituir um ato jurídico não há dúvida quanto à prévia e necessária previsão legal dos fundamentos que o autorizem. Nas hipóteses em que se produzem ou modificam efeitos jurídicos (diversamente de se extinguir), é preciso atentar com rigor para o preenchimento dos requisitos exigidos no plano material, não sendo dado ao juiz substituir propriamente a vontade das partes, mas os efeitos jurídicos a que estas se obrigaram, ou a que estão obrigadas por lei." (FLÁVIO LUIZ YARSHELL, Curso de Direito Processual Civil, volume I, 2ª edição, Marcial Pons, páginas 299-300 – os grifos não constam dos originais).

Dessa arte, como regra máxima, ao juiz não é dado contratar no lugar das partes. Ao tratar do tema concernente aos contratos de prestação e contratos de relação ou contratos relacionais, nomeadamente no que tange à ideia segundo ao qual é permitido aos Tribunais adaptarem ou revisarem as cláusulas contratuais, incluindo preços, dentro de um contexto em que as perdas de uma parte fossem compensadas pelo lucro obtido pela outra, obtempera a professora PAULA A FORGIONI: "Em muitos aspectos, essa linha compromete os vetores de funcionamento do próprio mercado, quando tratamos de relações entre empresas, especialmente naqueles em que inexistente relação de dependência econômica. Obrigar o agente econômico àquilo que não contratou, em nome do seguimento da relação contratual, no mais das vezes, implica exagerada ingerência nos negócios privados, em benefício exclusivo da outra parte – e não da fluência das relações de mercado e do desenvolvimento econômico." (PAULA A. FORGIONI, Contratos Empresariais – Teoria geral e Aplicação, 5ª edição, Thomson Reuters Revista dos Tribunais, páginas 64).

Em célebre julgamento, assim se pronunciou o STF:

Formação de contrato preliminar susceptível de adjudicação compulsória. - Cabe recurso extraordinário quando se discute qualificação jurídica de documento: saber se ele é mera minuta (punctação) ou contrato preliminar. - Distinção entre minuta, em que se fixa o conteúdo de certas cláusulas, mas se deixam em aberto outras, e contrato preliminar. - O art-639 do Código de Processo Civil pressupõe a existência de contrato preliminar que tenha o mesmo conteúdo (elementos essenciais e acidentais encarados objetivamente) que o contrato definitivo que as partes se comprometeram a celebrar. - Negativa de vigência, no caso, do art.191 do Código Comercial e do art. 639 do C.P.C. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 88716, Relator(a): MOREIRA ALVES, Segunda Turma, julgado em 11/09/1979, DJ 30-11-1979 PP-08985 EMENT VOL-01155-02 PP-00549 RTJ VOL-00092-02 PP-00250)

Para o Ministro MOREIRA ALVES, não se poderia dar execução específica ao acordo, porque isso implicaria transferir para o juiz aspectos negociais: "Não pode o julgador consagrar o que está por acertar, o que expressamente depende do futuro

entendimento e de valoração de dados ainda não colhidos. Se assim se fizer, estará o juiz contratando pelas partes, o que é grosseiro desvio de função e vício insanável do julgamento, pois se terá imposto em substituição às vontades necessariamente de se colher das Partes, emitindo, como acabadas e perfeitas, declaração de vontade que elas não fizeram". Todavia, mesmo para COMPARATO, o contrato preliminar apenas pode obrigar à contratação definitiva se encerrar consenso sobre todos os elementos essenciais à sua existência ou, pelo menos, for acordada a "determinabilidade dos seus elementos essenciais". Assim não fosse e dar-se-ia ao julgador o poder de negociar pela parte – o que é repellido por nosso direito positivo e por nossa tradição. "Não se admite, em nosso sistema jurídico, [...] que o juiz se substitua às partes para preencher os pontos em branco sobre os quais elas, apesar das negociações posteriores à minuta, não chegaram a acordo". Em conclusão, a disciplina imposta pelos arts. 462 e 463 do Código Civil formata-se à lógica própria ao direito comercial; as críticas que lhe têm sido deferidas não parecem ter muito fundamento. Obrigar as empresas a aceitar termos contratuais impostos por terceiros andaria a favor do interesse geral do comércio, do tráfico mercantil? Em nossa ordem jurídica, a resposta é negativa. Os acordos pré-contratuais podem ser relevantes do ponto de vista moral, e até mesmo auxiliar o bom andamento das negociações. Porém, sua execução específica, de forma a obrigar à celebração a parte que desiste do negócio, é bastante difícil." (PAULA A. FORGIONI, Contratos Empresariais – Teoria geral e Aplicação, 5ª edição, Thomson Reuters Revista dos Tribunais, páginas 78-79).

E por fim: "Os contratos reputam-se celebrados se e quando houver acordo quanto aos seus elementos essenciais. "O juiz não pode negociar pela parte" é um vetor importante a considerar, imposto pelo ordenamento jurídico." (PAULA A. FORGIONI, Contratos Empresariais – Teoria geral e Aplicação, 5ª edição, Thomson Reuters Revista dos Tribunais, página 81).

Por exemplo, o Código Civil aponta como fundamentos para a concessão da tutela constitutiva (tipicidade dos fundamentos ou da causa de pedir):

Art. 144. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa, a quem a manifestação de vontade se dirige, se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante.

Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.

(...)

§ 2º Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito.

Art. 442. Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato (art. 441), pode o adquirente reclamar abatimento no preço.

Art. 455. Se parcial, mas considerável, for a evicção, poderá o evicto optar entre a rescisão do contrato e a restituição da parte do preço correspondente ao desfalque sofrido. Se não for considerável, caberá somente direito a indenização.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato.

Art. 615. Concluída a obra de acordo com o ajuste, ou o costume do lugar, o dono é obrigado a recebê-la. Poderá, porém, rejeitá-la, se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza.

Art. 616. No caso da segunda parte do artigo antecedente, pode quem encomendou a obra, em vez de enjeitá-la, recebê-la com abatimento no preço.

Art. 770. Salvo disposição em contrário, a diminuição do risco no curso do contrato não acarreta a redução do prêmio estipulado; mas, se a redução do risco for considerável, o segurado poderá exigir a revisão do prêmio, ou a resolução do contrato.

A respeito do tema, assim se pronuncia FRANCISCO PAULO DE CRESCENZO MARINO: "Não parece haver, in abstracto, orientação normativa no sentido de prescrever idênticas posições jurídicas às partes de uma dada relação contratual. Ao contrário, o regime dos contratos típicos caracteriza-se pelo delineamento de direito e obrigações –

ou, mais precisamente de posições jurídicas ativas e passivas – distintos, conforme o polo da relação. A disparidade está relacionada à natural desigualdade de interesses dos contratantes, sobretudo em se tratando de contratos sinalagmáticos. Adotada a perspectiva da obrigação, tampouco se podem afirmar paritárias as posições tituladas pelo credor e pelo devedor da prestação. A mesma disparidade se verifica no tocante aos remédios ou meios de tutela de posições contratuais dispostos em lei. Por vezes, atribui-se a uma das partes o poder de pôr fim à relação contratual (v.g., anulando-a ou resolvendo-a), conferindo-se à outra, e somente a ela, o contrapoder de manter a relação adaptando-a. É o que se verifica em matéria de erro e de lesão, outorgando-se a uma só das partes (o destinatário da declaração emitida pelo errante e o credor da prestação cujo valor é desproporcional em relação à contraprestação, respectivamente) o poder de evitar a anulação do negócio jurídico (arts. 144 e 157, §2º do Código Civil). Outras vezes, os poderes extintivo e conservatório (modificativo) são titulados pela mesma parte, que pode optar pelo exercício de um ou de outro. É o que ocorre em tema de vícios redibitórios, cabendo ao adquirente (credor da coisa defeituosa), e somente a ele, os poderes alternativos de redibir o contrato ou obter o abatimento do preço, mantendo a avença (art. 442 do Código Civil). Também no regime da evicção parcial, a lei atribui apenas ao credor da coisa evicta os poderes extintivo e modificativo (mediante “restituição da parte do preço correspondente ao desfalque sofrido”) da relação contratual. Configuração semelhante pode ser encontrada na disciplina de certos tipos contratuais. Na empreitada, apenas o dono da obra é titular dos poderes extintivo e modificativo (abatimento de preço) do contrato em caso de obra realizada em desacordo com o contrato ou as normas técnicas (art. 615, segunda parte, e 616 do Código Civil). No seguro, são conferidas apenas ao segurado os poderes extintivo e modificativo (“revisão do prêmio”) do contrato no caso de diminuição superveniente e considerável do risco segurado (art. 770 do Código Civil). Como parece evidente, em nenhum dos casos acima referidos haverá igualdade de tratamento entre as partes contratantes, no sentido propugnado pela doutrina inicialmente referida, dado que uma delas estará necessariamente submetida à deliberação da outra quanto à eventual manutenção da relação contratual.” (Revisão Contratual, Onerosidade Excessiva e Modificação Contratual Equitativa, Almedina, páginas 46-47).

De outro vértice, impõe-se distinguir neste momento a impossibilidade de cumprimento da obrigação decorrente da excessiva onerosidade e a simples dificuldade pessoal de prestar que, logicamente, não autoriza a resolução ou a revisão do contrato.

Consoante pontifica ARNOLDO MEDEIROS DA FONSECA: “Com a impossibilidade absoluta não se confunde, portanto, a dificuldade da prestação.” (...) “Na ordem material, entretanto, a oposição entre os dois termos, impossibilidade e dificuldade, é clara: a dificuldade implica possibilidade mediante um certo esforço, devendo-se sempre procurar ter em vista a conduta de um homem-tipo. Tal é o preciso conceito de RADOUANT, aceito por BONNECASE, e que também adotamos. Desta forma, somente quando acarreta a impossibilidade objetiva ou absoluta de executar, seja natural ou jurídica, é que o caso fortuito extingue a obrigação. A onerosidade, mesmo excessiva, ou a dificuldade imprevista, não bastam para isentar o devedor de responsabilidade. Já vimos (ns. 75, 77 e 78 supra) que uma tal solução nada tem de iníqua, correspondendo, ao contrário, a uma necessidade social. Se, pois, a impossibilidade decorrer apenas das condições pessoais do obrigado, sem reflexos necessários sobre a própria prestação em si, de modo que não existiria para outro homem, colocado em análogas condições exteriores de tempo, lugar e meio, tendo-se em vista a natureza da própria prestação, de modo a constituir assim um impedimento meramente subjetivo, o caso fortuito não liberará o devedor. Nem mesmo quando se tratar de prestações pessoais, pensamos que se possa aceitar a doutrina de GIORGI, favorável à admissão da impossibilidade relativa como capaz de exonerar. Isto porque, uma de duas: ou o impedimento pessoal terá conexão necessária com a própria prestação, como no caso da doença do artista, inibindo-o de pintar o quadro a que se obrigou -, e, nesse caso, haverá verdadeira impossibilidade objetiva; ou então faltará essa relação de conexão – como se não teve recursos pecuniários ou

crédito para comprar tintas, e então, ocorrerá, na verdade, impossibilidade subjetiva, mas que não basta para liberar, pois não existiria necessariamente para outro, em condições análogas." (Caso Fortuito e Teoria da Imprevisão, 3ª edição, 1958, Edição Revista Forense, páginas 154/156 – grifei e destaquei).

Com relação à teoria da imprevisão, o artigo 478 do Código Civil dispõe que: "Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação." Consoante a dicção legal, para além da prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, o devedor deve demonstrar a extrema vantagem para a outra. A respeito do tema, trago à colação os valiosos ensinamentos do professor CUSTODIO DA PIEDADE UBALDINO MIRANDA: "À onerosidade excessiva da prestação de uma das partes, exige-se uma extrema vantagem da outra, como requisito da resolução, interessando saber qual o pensamento da lei no exigir os dois requisitos. Em regra, o contrato comutativo, a equivalência inicial das prestações acarretará a uma das partes certa vantagem, quando a outra, não obstante a onerosidade superveniente da sua prestação, tenha de cumpri-la, e essa vantagem será tanto maior quanto maior for a onerosidade da prestação em causa. Trata-se, por assim dizer, de uma vantagem em abstrato. Mas há que apurar quando uma onerosidade excessiva da prestação de uma das partes acarreta em concreto uma vantagem para a outra. O que a lei quer dizer é que não é qualquer onerosidade, resultante de acontecimento extraordinário e imprevisível, que fundamenta a resolução. Antes de mais, não basta uma onerosidade subjetiva, sentida pelo devedor em razão de outras obrigações que têm de cumprir contemporaneamente, ou por dificuldades financeiras do momento, mas terá de ser uma onerosidade excessiva, do ponto de vista objetivo, com abstração das condições pessoais do devedor, considerada tal por critérios de razoabilidade e particularmente em razão do valor claramente desproporcional às prestações que vinham sendo cumpridas pelo próprio devedor, tratando-se de obrigação de execução continuada, ou em relação à prestação do credor, nos casos de execução instantânea. Tanto num caso como no outro, pode ou não haver desproporção manifesta entre as prestações das duas partes; dizendo de outro modo, pode haver onerosidade excessiva da prestação para o devedor, mas nem por isso tal fato acarretar qualquer vantagem adicional para o credor. Neste caso, o devedor poderá pedir a correção do valor da prestação, se a problemática se limitar a isso, nos termos do art. 317. A resolução, porém, só poderá ser pedida quando, à onerosidade da prestação, acrescer um plus, uma vantagem extrema ao credor, que terá de ser demonstrada, apontando-se como que um nexo causal entre aquela onerosidade e esta vantagem. Trata-se, ao que parece, de uma exigência para se prestigiar o princípio da conservação dos contratos, pois só assim se compreende que a resolução possa ser evitada se aquela vantagem for passível de eliminação, mediante o oferecimento do devedor a modificar equitativamente as condições contratuais, que o juiz aceitará, precisamente por reconhecer que só assim restabelecerá o equilíbrio econômico do contrato." (Comentários ao Código Civil, Coordenador Antônio Junqueira de Azevedo, volume 5, Saraiva, páginas 442/443 – grifei e destaquei).

E a respeito dos equívocos da jurisprudência em matéria de revisão de contratos de consumo, assim se posiciona o mestre HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, em especial quanto ao suposto direito de rompimento unilateral do contrato pelo consumidor, sem a incidência de qualquer penalidade, por fator financeiro tão somente a ele devido: "Data máxima venia, a teoria da imprevisão agasalhada pelo art. 6º, inciso V, do CDC não se compadece com dificuldades pessoais de um contratante (impossibilidade relativa), mas refere-se a alterações conjunturais que criem obstáculos gerais ao cumprimento de certo tipo de contrato. Funda-se o permissivo de revisão contratual na teoria da base do contrato, que, sabidamente, não leva em conta problemas individuais de um dos contratantes. A ideia de ser cabível a revisão do contrato por quebra da "base de valoração do contrato" opõe-se à ideia de "segurança do tráfego", que exige a estabilidade formal dos vínculos. Só se pode, portanto, invocar a alteração da base do negócio "quando a segurança do tráfego não se oponha a tal". E isto só acontecerá quando a alteração da circunstância atingir não um dos

contratantes isoladamente, mas afetar a base de valoração “comum a ambas as partes”. Para falar-se em “onerosidade excessiva superveniente”, deve-se observar um critério objetivo, e não pessoal ou subjetivo, de modo que se possa afirmar que “a prestação é excessivamente onerosa por si mesma e não em relação a determinado devedor. Tal como o Código Civil italiano, o CDC brasileiro não fala em revisão do contrato em razão de fatos supervenientes que tornem “as prestações excessivamente onerosas para uma das partes”, mas, sim, e apenas, que “as tornem excessivamente onerosas”.” (Direitos do Consumidor, 10ª edição, Editora Forense, páginas 294). Conforme a teoria de SCHMIDT-RIMPLER acerca da denominada “base de valoração do negócio”: “O princípio contratual devidamente entendido manifesta como injustas as consequências jurídicas do contrato quando uma das partes assente numa valoração incorreta ou quando a base de valoração desapareça posteriormente. A esta conclusão, conforme com o princípio contratual, opõe-se a ideia de segurança do tráfego, que requer a estabilidade formal dos vínculos; a não verificação ou supressão da base de valoração do negócio só se tornam eficazes quando a segurança do tráfego não se oponha a tal. Essa não oposição ocorre quando a base de valoração seja comum a ambas as partes.” (apud Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da Boa-fé no Direito Civil, Almedina, páginas 1064/1065 – grifei e destaquei). Em face do exposto, julgo improcedente os pedidos formulados nos embargos.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de junho de 2022.

Miguel Ferrari Junior

Juiz de Direito